

1500443-39.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... informações que possuíam acerca do tráfico de drogas no local, e por fim, encontram uma grande quantidade de drogas com o réu, e da forma em que foram localizadas, evidenciam sobremaneira a traficância no local, graças à rápida e eficaz atuação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas.

Até porque, a própria genitora do réu, Sr.^a Rosimeire Aparecida, autorizou e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500443-39.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500443-39.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNNY FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JOHNNY FERREIRA DA SILVA, qualificado às fls. 08/09, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 180, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 09 de maio de 2021, por volta das 16h45min, na Rua São Manoel, n.º 158, Jardim Marisa, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, o DENUNCIADO mantinha em depósito 05 (cinco) invólucros plásticos contendo 253,55g (duzentos e cinquenta e três gramas e cinquenta e cinco centigramas) de crack e 07 (sete) invólucros plásticos contendo 5,27g (cinco gramas e vinte e sete gramas) de crack, embalados em uma sacola plástica, para fins de fornecimento a terceiros, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 15/18), fotografias (fls. 19/22) e laudo pericial definitivo de

fls. 114/116. Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, entre o dia 30 de abril e 09 de maio de 2021, em horário incerto, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, o DENUNCIADO adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular da marca XIAOMI, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 15/18) e auto de entrega de fl. 112. Segundo apurado, o denunciado mantinha o entorpecente acima descrito em sua residência para fins de comercialização. No exercício da mercancia ilícita da mercancia ilícita de entorpecentes, o denunciado adquiriu o aparelho celular da marca Xiaomi, subtraído da vítima Wendel Michel Mião no mês de abril do ocorrente ano, nesta cidade e comarca, ocasião em que o ofendido deixou momentaneamente o aparelho celular no interior de seu veículo com as portas destravadas e vidros abertos. Terceiro não identificado subtraiu o bem e repassou ao denunciado, possivelmente em troca de entorpecentes. O denunciado adquiriu a res furtiva tendo conhecimento de que se trata de produto de crime, já que desprovida de acessórios básicos e nota fiscal, afora o fato de o ofendido ter enviado uma mensagem ao aparelho no afã de recuperá-lo, com os seguintes dizeres: OI! VOCÊ ENCONTROU MEU TELEFONE. FICAREI EXTREMAMENTE AGRADECIDO SE ENTRAR EMCONTATO" COM O NÚMERO 18-98801-2629 - fls. 15/18. Paralelamente, Policiais Militares receberam informação de que no dia 09 de maio do corrente ano o denunciado estaria na posse de aparelhos furtados e iria comercializá-los nas imediações da Rua Francisco Drimel, n.º 105. O denunciado chegou ao local pouco antes da chegada dos policiais, portando 05 (cinco) celulares, incluindo o aparelho acima descrito. Com a abordagem, nada de ilícito fora encontrado com ele, com exceção do telefone móvel subtraído. Porém, os policiais também detinham prévia informação da realização de tráfico de drogas por JOHNNY. Em prosseguimento as diligências, os policiais, juntamente com o denunciado, dirigiram-se a residência dele situada na Rua São Manoel, n.º 158, nesta cidade e comarca, onde ele mantinha em depósito 05 (cinco) invólucros plásticos contendo 253,55g (duzentos e cinquenta e três gramas e cinquenta e cinco centigramas) de crack, localizadas dentro de uma estante e, ainda, 07 (sete) invólucros plásticos contendo 5,27g (cinco gramas e vinte e sete gramas) de crack, localizadas dentro de uma lata de bala vazia sobre o armário da cozinha, além da quantia de R\$5.799,00 (cinco mil, setecentos e noventa e nove reais), sendo R\$470,00 (quatrocentos e setenta reais) em moedas e o restante em cédulas diversas, divididos em duas latas vazias de leite guardadas no rack da sala da casa. Ainda na cozinha, próximo à droga, foi localizada uma tesoura e embalagens plásticas utilizadas no preparo do entorpecente a ser alienado. Considerando a apreensão de entorpecente já separado e embalado para a venda, bem como de grande quantidade já fracionada para ulterior revenda, não há dúvidas de que a substância entorpecente apreendida tinha como destino a mercancia ilícita. Acresça-se, outrossim, a razoável quantia em dinheiro apreendida, fruto da mercancia ilícita. O aparelho celular subtraído foi restituído ao ofendido - fl. 112. Os aparelhos restantes serão objeto de apuração em autos próprios (fl. 113)". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial.

Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 158/161), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 165), o despacho de fls. 166/170, de 26 de julho de 2021, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas.

Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 308/313), pediu a procedência da ação penal, condenando o réu nos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor Público (fls. 317/335), arguiu preliminarmente, a ilicitude da prova angariada aos autos, vez que o ingresso de policiais militares no interior do imóvel residencial dos autuados, sem o correspondente mandado de busca e apreensão, viola o direito constitucionalmente garantido à inviolabilidade de domicílio. Argumenta ainda que as autoridades policiais devem se valor de meio audiovisual para legitimar da ação policial. Também pugna pela invalidação das provas obtidas por da quebra da cadeia de custódia no momento da apreensão da droga, devendo ser consideradas ilegítimas, em afronta ao artigo 158-A, do Código de Processo Penal, devendo ainda ser preservado o local pela Polícia a fim de possibilitar o contraditório e a ampla defesa, com documentação e registro de todo o percurso do vestígio, e mais, a exigência legal é mínima diante da maior segurança que confere

ao elemento de prova, bem como da viabilidade de efetivo contradição deste pela defesa. Em outras palavras, o que a lei impõe é que não se altere a “cena do crime” antes de realizados os atos de coleta da prova, de tal forma que, alega não ter sido preservado o local do encontro da droga, não podendo ser assegurado que o entorpecente não tenha sido plantado na residência do réu, portanto, não foi respeitada a exigência de isolamento, fixação, coleta, acondicionamento e transporte dos entorpecentes apreendidos, em afronta ao disposto no artigo 158-A, §1º, e 158-C, II, III, IV e V, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, o auto de exibição e apreensão, portanto, é prova lícita direta; ao passo que o exame toxicológico e demais elementos colhidos em juízo, são ilícitos por derivação e, portanto, igualmente também não se prestam à condenação. No mérito, pugna pela absolvição do réu, por insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e quanto ao crime de receptação, pugna pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, ante ao princípio da insignificância, uma vez que sequer foi submetido à avaliação do objeto e este prontamente restituído ao seu legítimo proprietário. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, que seja aplicada a pena no mínimo legal, em regime diverso do fechado, e que a pena cumprida provisoriamente seja abatida ao montante da pena aplicada, conforme dispões do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal. Que seja reconhecida a confissão espontânea quanto ao crime de receptação. Requer também que a pena corporal seja substituída por restritiva de direitos, já que preenche os requisitos legais do artigo 44, §3º, do Código Penal, e a reincidência não é específica. É o relatório.

DECIDO.

Ab initio, a alegação de falta de mandado de busca e apreensão, autorização do réu ou justa causa para a entrada dos policiais militares em sua residência não tem o condão de desnaturar a validade das diligências efetuadas, diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas e conseqüentemente, da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes estatais, não se mostra possível alegar a referida garantia constitucional.

No caso dos autos, tais circunstâncias mostram-se suficientes para o afastamento de qualquer alegação de nulidade da prova.

Até porque havia fundadas e sérias razões para se ingressar na residência do réu, diante das informações que possuíam acerca do tráfico de drogas no local, e por fim, encontram uma grande quantidade de drogas com o réu, e da forma em que foram localizadas, evidenciam sobremaneira a traficância no local, graças à rápida e eficaz atuação da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas.

Até porque, a própria genitora do réu, Sr.^a Rosimeire Aparecida, autorizou e franqueou o ingresso dos policiais militares em sua residência, conforme disse a fl. 52, e disse ainda que polícia encontrou “crack” na cozinha de sua residência, e depois de toda a ação policial teve que ser contida porque se rebelou com um dos policiais tendo que ser contida por eles.

Ora, não se mostra razoável o pedido de invalidação das provas, como quer fazer crer o Defensor Público, imputando aos Policiais Militares que ingressaram sem autorização judicial ou de qualquer morador da residência, tentando macular o trabalho e ação policial legítima, tentando a todo custo desqualificar suas condutas de modo a livrar o réu da grave acusação de tráfico de drogas, crime que corrompe toda uma multidão de jovens em nosso país, e que cada dia mais alimenta sobremaneira outros tantos tipos de crimes graves, como roubo e latrocínio praticados por viciados a fim de quitarem suas dívidas e adquirirem mais drogas dos traficantes.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. RECORRENTE ABORDADA EM VIA PÚBLICA, OCASIÃO EM QUE FOI ENCONTRA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS, ANTES DA ENTRADA DOS AGENTES EM DOMICÍLIO ALHEIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - No que tange ao pedido de reconhecimento de nulidade, pela ausência de mandado de busca e apreensão, insta consignar que tanto a jurisprudência desta Corte, como a do eg. Supremo Tribunal Federal, firmaram o entendimento no sentido de que, tratando-se de crime permanente, como é o delito de tráfico de entorpecentes mostra-se prescindível o mandado judicial, em caso de flagrante, como na hipótese. III - No caso, sub examine, no qual se alega a ocorrência de irregularidade face a ausência de mandado judicial, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a atuação dos agentes policiais no sentido de ingressar em domicílio alheio teve como elementos precursor e a abordagem realizada em via pública, "[...]momento que encontraram pequena porção de substâncias entorpecentes", bem como informação acerca da existência de mais droga no local em que ela reside, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante. IV - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. V - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a contumácia delitiva da ora Agravante, porquanto, consoante se deduz dos autos, a conduta, em exame, não é fato isolado na sua vida, tendo o magistrado primevo ressaltado na decisão objurgada que ela "já responde a outra ação penal também pelo crime de tráfico de drogas (0007559-75.2018.805.0191), onde foi concedida liberdade cumulada com medidas cautelares diversas da prisão", circunstância que indica a periculosidade concreta da agente, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC140.998/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Segundo o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1281760AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020).

É que quando se trata de crime permanente, como o porte de arma e no caso dos autos, não há a invasão preconizada, pois a flagrância protraí-se no tempo, podendo, a qualquer momento, o policial prender o réu. Existe, ainda, exceção à necessidade de mandado de busca e apreensão. Não existe, pois, violação de preceito constitucional, art. 5º, XI, da Carta Magna, ou legal (art. 303 do Código de Processo Penal).

A prisão foi feita em conformidade com os ditames legais. O direito em análise não é absoluto quando há flagrância, pode-se agir, caso contrário, outro tipo de violação poderia ocorrer, até mais grave. "Este Tribunal Superior prega que, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, a sua consumação se protraí no tempo, de sorte que a situação de flagrância configura-se enquanto o entorpecente estiver sob o poder do infrator, sendo possível, portanto, em tal hipótese, o ingresso na residência, ainda que não haja mandado de prisão ou de busca e apreensão, já que incide a excepcionalidade inscrita no art. 5º, inciso XI, da CF, a afastar a inviolabilidade do domicílio" (HC 208957/SP- 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS) - J. 6.12.2011 - DJe 19.12.2011). Cf., ainda, HC 101628/SP - 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora convocado do TJ/MG) - J. 21.10.2008 - DJe 10.11.2008; HC77489/AM- 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura - J. 12.2.2008 - DJe 17.3.2008; HC 40056/SP - 6ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Hamilton Carvalhido - J. 30.6.2005 - DJ 05.09.2005, p. 493; HC 32934/GO- 5ª do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Gilson Dipp - J. 28.4.2004 - DJ 14.6.2004, p. 258 e RHC 14946/SP - 5ª T. do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - J. 1.4.2004 - DJ 03.05.2004, p. 184 e REVFOR vol. 375, p. 406).

O C. Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: 'A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori' (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

E que tal fato, mesmo não tendo ocorrido, já que a genitora deste, autorizou a entrada dos Policiais Militares em sua residência, não havendo nenhuma prova em contrário de que houve qualquer tipo de impedimento ou recusa.

Tal matéria, todavia, foi suscitada novamente e em reexame do tema pelo Superior Tribunal de Justiça e no julgamento de Habeas Corpus nº 598.051 - SP (2020/0176244-9) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no dia 2/3/2021, decidiu:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. [...] 9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e conseqüente absolvição do

paciente [...] (HC 598.051/SP. MATÉRIA CRIMINAL. Relator Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 6ª Turma. JULGADO: 02/03/2021. Publ. 15/03/2021).

O Min. Relator Rogério Cruz justificou a decisão da turma em que, somente fundadas razões e desconfianças dos agentes do estado, não são suficientes para o ingresso sem mandado judicial na casa do suspeito, e além disso, “deve haver documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado, seja toda registrada em áudio e vídeo, de maneira a não deixar dúvidas quanto a legalidade da ação estatal e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado”. Entretanto, tal matéria foi objeto de análise em sede de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e teve como Relator Min. Alexandre de Moraes, que decidiu de acordo com a repercussão geral daquela Corte quando descreve “o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide”. Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, conseqüentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Também ponderou que a TESE é de que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”.

Sem mais aprofundamento sobre a matéria e esgotada toda e qualquer discussão acerca do tema, merece então trazermos a parte final do julgamento que ocorreu no dia 02/12/2021, pelo Ministro Alexandre de Moraes, conforme segue:

“Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa)[...].”

Portanto, sobre todos os ângulos de análise, mostra-se absolutamente descabida a tese de nulidade baseada na “Teoria dos frutos da árvore envenenada” e em suposta violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, afastando-se o pleito defensivo.

E em uma segunda preliminar arguida pelo Defensor Público por quebra da cadeia de custódia, por não ter sido observadas as regras contidas no artigo 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, pelos Policiais Militares, já que não providenciaram o isolamento do local para que a Polícia Técnica pudesse comprovar que a droga encontrada estava realmente no local onde disseram os Policiais que estava, de modo que também não documentaram a fixação e coleta de vestígios, com acondicionamento, transporte e processamento de forma ininterrupta.

Rejeito a preliminar arguida pelo nobre Dr. Defensor Público, que alega nulidade da prova porque não foi observada ou obedecida ou mantida a chamada CADEIA DE CUSTÓDIA, instituída no Código de Processo Penal, pela recente reforma processual da lei n. 6.341/2019, mais conhecido como “pacote anticrime”.

A não observância das regras da Cadeia de Custódia não gera nulidade ou ilicitude da prova, porque há outras formas de se reconhecer a autenticidade da prova.

No caso dos autos o acusado e sua defesa negam a autoria, mas alegam que a prova foi produzida de maneira a não observar os preceitos para preservação do local, colheita, acondicionamento, transporte, o local onde foi colhida a prova.

Ora, se a prova foi produzida a partir da colheita de material no local dos fatos, onde se demonstrou claramente e sem qualquer resquício de dúvidas que a droga foi encontrada na cozinha da casa do réu ou de sua genitora. Fato é que a própria

genitora, como dito alhures, também na preliminar de invasão de domicílio arguida pelo Defensor que os policiais encontraram a droga na casa dela, mais precisamente na cozinha da sua residência, conforme consta em suas declarações de fl. 52, somente para ilustrar que os policiais agiram dentro do estrito dever e da legalidade, não havendo nenhum vestígio de mácula ou de que os Policiais Militares intrujaram droga na residência para incriminar falsamente o acusado, que já era bastante conhecido no bairro e pelos policiais militares.

Trago a colação, a lição do brilhante jurista, Gustavo Badaró:

"A Cadeia de Custódia e sua Relevância para a Prova Penal. In: SIDI, Ricardo; LOPES, Anderson Bezerra (Org). Temas Atuais da Investigação Preliminar no Processo Penal. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2017, p. 533.

Complementa o autor: "(...) as irregularidades da cadeia de custódia não são aptas a causar a ilicitude da prova, devendo o problema ser resolvido, com redobrado cuidado e muito maior esforço argumentativo, no momento da valoração (...) se considerar atendível um meio de prova, decorrente de fonte sobre a qual haja irregularidades na cadeia de custódia, haverá uma inegável necessidade de reforço justificativo demonstrando o porquê ser possível confiar na autenticidade". (p. 535-536).

Ressalte-se, outrossim, que o inquérito é mero procedimento administrativo-informativo, razão pela qual as investigações realizadas pela autoridade policial não se confundem com instrução criminal, motivo pelo qual eventuais irregularidades por integridade de tal fonte, porventura nele ocorridas, não são capazes de ensejar nulidade do processo, nem muito menos das provas colhidas no local dos fatos, o qual, no caso em análise, transcorreu de forma regular e sem vícios.

Oportuno, ainda, frisar que "em processo penal, vigoram os princípios de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP)" (STJ 5ª Turma, RHC nº 38.424/MG, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 07/03/2005).

Dessa forma, não prospera a arguição do Defensor Público de a Polícia Militar não respeito ou observou os mandamentos impostos no artio 158-A, do Código de Processo Penal, até porque, não se trata de crime onde a perícia deve comparecer para averiguar e constatar, por exemplo, o ingresso do réu numa residência, ou a morte de uma pessoa, ou seja, houve o encadeamento regular na colheita de provas por parte dos policiais militares que apresentaram logo após ocorrência, o réu e todo o material e objeto do crime que serviram de provas para instruir o presente processo.

No caso, observa-se que são afirmações vazias e sem fundamento, até porque, essa "suposição" do i. Defensor, foi trazida aos autos no afã de que pudesse levar a nulidade do processo e isentar o réu de seus crimes. Ademais, a estranheza permanece, pois necessita de provas, firme e segura da ocorrência da quebra na cadeia de custódia na colheita da prova, o que não se vê e nem se produziu nos autos, tornando tal alegação ao menos inócua, diante da gravidade das afirmações. Por todo o exposto, é que não acolho nenhuma das preliminares arguidas pelo Defensor Público.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/18; pelas fotografias de fls. 19/22; laudos de constatação preliminar de fls. 25/27; pelo laudo químico toxicológico de fls. 114/116, atestando - Item A (Acondicionado sob o lacre 0035273) Descrição: 5 (cinco) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por aquecimento encerrando porção de material sólido petrificado, de cor bege. Massa Bruta e/ou Quantidade: 259,45 grama(s) - duzentos e cinquenta e nove gramas e quarenta e cinco centigramas. Massa Líquida: 249,43 grama(s) - duzentos e quarenta e nove gramas e quarenta e três centigramas. Item B (Acondicionado sob o

lacre 0035274) Descrição: 7 (sete) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando porção de material sólido petrificado, de cor bege. Massa Bruta e/ou Quantidade: 10,76 grama(s) - dez gramas e setenta e seis centigramas. Massa Líquida: 4,95 grama(s) - quatro gramas e noventa e cinco centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial de objetos de fls. 1117/119 que analisou: Item A (Acondicionado sob o lacre 0015877) Descrição: 1 (uma) tesoura escolar, da marca "LEO&LEO", constituída por duas lâminas metálicas cortantes, unidas por um eixo, sendo que uma apresentava graduação em centímetro, apresentando resquícios/sujidades. Tal peça pode ser utilizada para fracionar entorpecentes. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) e Item B (Acondicionado sob o lacre 0015875) Descrição: 1 (um) recipiente de metal, paralelepipedal, apresentando diversas inscrições, entre elas "MENTOS", dotado de tampa própria, apresentando resquícios/sujidades. Tal peça pode ser utilizada para acondicionar entorpecentes. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020) e Item C (Acondicionado sob o lacre 0015876) Descrição: embalagens plásticas, daquelas utilizada para embalar "geladinho", novas, apresentando resquícios/sujidades externamente, acondicionados no interior de embalagem plástica apresentando diversas inscrições, entre elas "START FESTAS". Tais peças podem ser utilizadas para embalar geladinhos. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); pelo laudo pericial no aparelho celular de fls. 268/300; além da prova oral carreada para os autos.

A testemunha PM. Diego da Silva Lobo, sob o crivo do contraditório, declarou que estavam em patrulhamento e houve uma denúncia anônima que esse indivíduo Johnny estava fazendo venda de celulares na Rua Francisco Drimel, e lá chegando fomos recebidos pelo proprietário, e informado da denúncia, autorizou a entrada em sua residência e numa residência nos fundos onde seu filho reside, encontramos o Johnny e outros indivíduos que não se recorda do nome. Johnny estava na posse de cinco celulares, e um deles tinha uma mensagem na tela de que o aparelho havia sido furtado, e questionado, informou que ele fazia rolo, comprando e vendendo celular na feira do rolo, e indagado se em sua residência havia algo de ilícito, respondeu negativamente, e informou o endereço de sua mãe. Já tínhamos conhecimento de que ele não morava mais com sua genitora, e já havia denúncias de tráfico de droga praticado pelo acusado em outra residência, deslocamos a equipe até lá e encontramos a mãe e a esposa dentro da residência, e acabamos localizando pedras de crack na cozinha, outra poção de crack na estante, e dinheiro numa almofada no sofá. Acionado o canil, foi localizado mais dinheiro e drogas, não se recorda a quantidade. Confirma que junto com as primeiras drogas localizadas, também tinha uma tesoura, saquinhos para embalar a droga. A quantia de dinheiro encontrada na almofada, era pouco mais de R\$ 400,00, mas com o auxílio do canil, foi localizado mais R\$ 5.000,00, entre moedas, mais de R\$ 5.800,00. Quanto aos celulares, na Delegacia, fizemos contato com a pessoa do celular que confirmou ter sido furtado, mas não houve acareação naquele momento. Quanto aos celulares localizados, estavam todos dentro de uma sacolinha em posse de Johnny. Já os saquinhos e a tesoura foram localizados na cozinha, num armário, e disse que apenas guardava o entorpecente, que não lhe pertencia. Afirma que não havia doces ou outro produto para embalar com tais saquinhos encontrados

A testemunha PM. Paulo Henrique de Melo, sob o crivo do contraditório, declarou que nesta data recebemos denúncia sobre celulares furtados, e nos deslocamos ao local indicado na denúncia. Em contato com o proprietário da residência, nos disse que

algumas pessoas teriam entrado na residência dos fundos, que eram colegas do filho dele, umas cinco pessoas. Foi solicitado o ingresso na residência e autorizado, onde foi localizado de cinco a seis indivíduos, inclusive Johnny com alguns celulares, e um dele já estava na tela a programação para entrar em contato com a pessoa proprietária do aparelho que este havia sido furtado, que fizemos contato. Indagado, Johnny disse que fazia a venda pela OLX e que aqueles aparelhos eram referentes a troca e comprar de celulares, porém, um deles, após contato com o proprietário, realmente disse que havia sido furtado. Em continuação a entrevista com o réu, foi indagado se havia algo mais de ilícito na residência, e este negou, passando um endereço, mas já sabíamos que ele não residia mais nesse endereço, mas estava morando com a mãe. Nos dirigimos para este endereço e localizamos a mãe e a amasia deste na residência, e em contato com ela, disse que não havia nada de errada na residência e os convidou para entrar. Dentro do imóvel, em cima de um armário na cozinha, localizamos algumas pedras de crack, amarradas, prontas para venda, inclusive outros objetos usados na embalagem da droga, sacolé, tesoura, faca..., e dentro de uma almofada que estava em cima do sofá, localizamos dentro desta uma quantia em dinheiro, e solicitado o apoio do canil, que abaixo de uma estante, foi localizado mais dinheiro, cerca de R\$ 5.000,00, em espécie e mais uma outra quantidade de droga. Indagado sobre a droga, assumiu a posse, porém disse que guardava para uma pessoa, mas que não revelou a identidade desta pessoa. A testemunha Wendel Michel Mião, sob o crivo do contraditório declarou que a respeito do celular, mora ao lado do shopping americana, e a garagem é aberta, e não viu quem roubou, mas roubaram seu celular, óculos e dinheiro que estavam dentro do seu carro. Bloqueou o celular para que pudesse usar, e a polícia encontrou seu celular, e ligaram e disseram que estavam com esse indivíduo. O réu Johnny Ferreira da Silva, em seu interrogatório, declarou que já foi preso e processado anteriormente, e sobre os fatos disse que no dia dos fatos foi abordado em uma residência, onde estava fazendo a venda de aparelhos telefônicos, e algum deles havia uma mensagem de bloqueio dizendo "perdi meu telefone, se você encontrar por favor entre em contato", não tinha nada dizendo que era produto de furto ou roubo, e havia acabado de sair e comprou esse telefone para usar. Confirmar que fazia venda sim, que comprava celulares, bicicleta, vídeo games, moto e revendia, vivendo de rolo para sustentar sua família. Quando foi vender o telefone, se deparou com a polícia e foi abordado e perguntaram da origem dos aparelhos e disse que teria ido até aquela residência para vender um aparelho para o dono da casa, mostrei mensagem onde nós fazíamos negociação, então pediram seu endereço, que era a casa de sua mãe, e se morava em outra casa, confirmando que também morava numa casa no Jardim Planaltina, mas não sabia o endereço, pois fazia dez dias estava nesta residência, mas que poderia leva-los até lá, caso fosse preciso. Em continuação a ocorrência, foi trazido o canil e ficou na residência das 17:00 até as 19:30 ou 20 horas e depois disso o colocaram na viatura e rumaram para sua casa onde morava, que deu a indicação, não a casa de sua mãe. Chegando lá já havia várias viaturas na frente e estava junto com seu irmão de dezessete anos, e tiraram-no e o deixaram sozinho, quando apareceu sua mãe algemada, e lhe disseram que ela tinha desacatado o Policial. Foi conduzido à Delegacia, acreditando que era somente pela receptação que foi acusado, que o telefone era roubado. Enquanto prestava depoimento, foi lhe apresentada uma quantia de droga, e dinheiro, mas afirma que o dinheiro realmente lhe pertencia, fruto desse trabalho que fazia, depois que saiu, há oito meses, trabalhava de diária, vendia bolo de pote, que estava conseguindo manter uma renda, quando aparecia uma moto barata comprova para revender. Que tem como provar a origem do dinheiro, pois tem depósitos de R\$ 20, de R\$ 30,00 em sua conta, via pix, de clientes para quem vendia pão, bolo, vendia produto na rua, vendia cadeira de área e tem esses valores em sua conta até chegar no valor que estava em sua residência. Na delegacia então lhe apresentaram cerca de 200 gramas de droga, que depois o Delegado lhe disse que era crack, e lhe disse que não tinha conhecimento de droga, que sabia somente do telefone que teria sido conduzido, tendo o Delegado dito que, ou assumiria a droga ou quem estava na residência iria preso, sua mãe e sua esposa e as crianças para o Conselho Tutelar. Que em razão de tudo isso, assumiu a propriedade da droga e sua mãe e esposa foram

liberadas. Quer informar ainda que após ser colocado em liberdade, a polícia invadiu por três vezes a sua residência, a Polícia Militar, e Polícia de rotina e uma pelo BAEP, e nesse novamente forjaram a droga, a balança, e que tem conversa com o policial gravada, pois ele chamou para negociar e pediu para eu arrumar uma arma de fogo e o colocaram preso novamente.

1. Quanto ao crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06. A negativa do réu não pode ser acolhida, posto que além de não ser confirmada pela prova dos autos, está desmentida por ela, que demonstra de forma segura que os fatos se passaram como narrados na denúncia e a autoria deles pelos réus, além disso, o réu apresentou justificativas, principalmente quanto ao dinheiro apreendido dizendo que era da venda de pães e bolos de pote, cadeiras de área, entre outras coisas que vende na rua, além de diversos outros negócios, todos sem qualquer comprovação lícita, como compra e venda de celulares, objetos e até veículos, mas nenhuma prova da sua alegação, caindo em total descrédito diante de tudo o que foi amealhado aos autos.

Teria ele como fazer prova das suas alegações, apresentando qualquer documento válido ou até mesmo testemunhas, imparciais, de que todo o dinheiro encontrado em sua residência era fruto de trabalho, independente se formal ou informal, mas já se nota que seus negócios envolviam sempre algum ilícito, como no caso dos telefones encontrados com o réu, que não fez prova da sua titularidade e além do mais, um deles já identificado a vítima de onde fora furtado, e sem qualquer justificativa, de como tal aparelho foi parar em suas mãos.

Por outro lado, o depoimento dos policiais militares foi uníssono, sem qualquer exagero ou discrepâncias de versões, denotando que cumpriram fielmente sua missão e acabaram localizando grande quantidade de drogas, utensílios usados para preparação das drogas para futura venda, além de uma grande quantia em dinheiro, mas de R\$ 6.000,00.

O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))"

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do

comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento" (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que "em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário" (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que "pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis" (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278). Tais fatos e testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não só da droga mas também do dinheiro, que certamente recebera decorrente da venda do entorpecente, num total de R\$ 5.799,00 (cinco mil e setecentos e noventa e nove reais), em dinheiro, cédulas diversas, valores que denotam a venda de drogas, ao contrário do que disse em seu interrogatório, que é dinheiro da venda de bolos e pães, e cadeiras que venda na rua, que não merecem ser acolhidas, pois não convence, mas aliada aos demais objetos e a droga, várias pedras brutas que pesaram cerca de 253,55 gramas de crack, que renderia muitas pedras fracionadas para a venda, além dos saquinhos plásticos e tesoura, objetos que são usados para o fracionamento e embalagem da droga.

Ainda com o réu, havia nove aparelhos celulares, que como é de conhecimento, são trocados por usuários por drogas, e certamente são produtos de crime, como aquele que acabou sendo usado para descobrir todo o engenho criminoso do réu.

Por tudo isso, demonstrada, á saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu. Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar, inclusive, que os objetos encontrados e todos aqueles celulares, demonstram a principal destinação das drogas.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induze a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.). "ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745); "Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

A isso tudo se alia o constatado pela perícia no celular apreendido de propriedade do réu (fls. 268/300), onde se constatou muitas fotos de drogas, balança de precisão, entre outros objetos e muito dinheiro, que condizem com a soma localizado na casa do réu, bem como a fl. 273, onde foi localizado um vídeo em que foi gravado por quem executou a gravação:

"Tá vendo aí parceiro? Já vê o videozinho depois cê apaga. Ó, nozinho pequenininho entendeu ó? Cortinho de ladinho, na parte de baixo dele, só tem uma entendeu ó? Que é o final dele, certo ó? O baguio tá indo aí falou? O memo risco que tava lá na outra, cadê? Tá aqui o memo risco, tá vendo? Pode olhar lá no (palavra incompreensível), esse risco aqui, é a marcação, entendeu truta?".

Note-se que a droga embalada é idêntica aquela apreendida com o réu, pronta para ser vendida (fl. 21). Verifica-se igualmente, a fl. 284, a grande quantia em dinheiro, que também revela o lucro dos traficantes na venda de